

1500793-25.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, que o agravante se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500793-25.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109078/2022 - 01º

DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 24457891 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, BE6158-1/2022 - 1º Distrito Policial de Mauá, 2109078 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS COSTA CARDOSO LANDIM e outro

Data da Audiência:

22/06/2022

Réu Preso

Em 22 de junho de 2022 às 13h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réus privados de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, os acusados e os Defensores reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando

o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Presente o réu Mateus Costa Cardoso Landim. Presente o Advogado, Dr. Wendel Bernardes Comissário (OAB/SP 216.623). Presente o réu João Vítor Viana da Silva. Presente o Advogado, Dr. Claudemir de Oliveira (OAB/SP 387.533). Iniciados os trabalhos, o Ministério Público se opôs a juntada do link (gravação audiovisual). Pelo MM. Juiz foi dito: "1) Dispensar as imagens requisitadas à TV Bandeirantes, porque a emissora não as encaminhou, conforme requerido (fls. 227/228, 238, 241, 251 e 256). 2). Indefiro a juntada do link da suposta gravação da TV Bandeirantes, requeida pela defesa do réu Mateus (fls. 254/255), porque não se trata de imagens encaminhadas pela emissora, sendo tais imagens retiradas da internet e não se sabe a sua origem (fls. 254/255), como também as juntadas pelo cartório (fls. 253). Em seguida pelo MM. Juiz foram interrogados os réus. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. MATEUS COSTA CARDOSO LANDIM, qualificado às fls. 27, E JOÃO VITOR VIANA DA SILVA, qualificado às fls. 30, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 29, do Código Penal, porque, no dia 21 de abril de 2022, por volta de 17h:40min, na Travessa Ubajara, nº 200, - Jardim Rosina, nesta cidade e comarca de Mauá, previamente ajustados e com unidade de designios, vendiam, traziam com eles e guardavam, para entrega a consumo de terceiros, 49 invólucros plásticos contendo 43,96 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC), conhecido por maconha (Item 1); 75 invólucros plásticos contendo 46,02 gramas de cocaína (Item 2); 30 invólucros plásticos contendo 6,87 gramas de cocaína, na forma de crack (Item 3); substâncias entorpecentes ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20, laudo de constatação de fls. 22/25 e laudo toxicológico definitivo, que será oportunamente juntados aos autos (fls. 140/141). Foi convertida a prisão em flagrante dos acusados em preventiva (fls. 58/59). A denúncia foi oferecida (fls. 138/139). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 142/147). Os réus foram notificados (réu João Victor - fls. 210 - e réu Mateus - fls. 211) e apresentaram defesa preliminar (réu João Victor - fls. 174/176 - e réu Mateus - fls. 191/192). A denúncia foi recebida (fls. 193). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Marcos Luis da Silva (fls. 227/229), Marcelo Scorzelli (fls. 227/229), Willian Isaac da Silva (fls. 227/229), Wesley Chande Carvalho de Souza (fls. 227/229) e Valdecino Gonçalves Ferreira (fls. 227/229), e, por fim, procedeu-se o interrogatório dos réus João Vitor Viana da Silva (gravação audiovisual) e Mateus Costa Cardoso Landim (gravação audiovisual). Em audiência, o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Willian Isaac da Silva (fls. 227/228). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Marcelo Scorzelli (fls. 7/8), Marcos Luis da Silva (fls. 9) e Willian Isaac da Silva (fls. 10/11) e os réus João Vitor Viana da Silva (fls. 12) e Mateus Costa Cardoso Landim (fls. 13). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação dos réus e o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa dos réus Mateus, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direito (gravação audiovisual). A defesa do réu João Vitor, em debates, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para o crime do

artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no máximo, o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direito (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/4). Auto de exibição e apreensão (fls. 20). Laudo de constatação provisória (fls. 22/25). Laudo de exame de corpo de delito do réu Mateus (fls. 163/164). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 165/167). Folha de antecedentes (réu Mateus - fls. 44 - e réu João Victor - fls. 49) e certidão (réu Mateus - fls. 47/48 - e réu João Victor - fls. 52/53). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/4), auto de exibição e apreensão (fls. 20), laudo de constatação provisória (fls. 22/25), laudo de exame de corpo de delito do réu Mateus (fls. 163/164), exame químico toxicológico definitivo (fls. 165/167) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. A testemunha Marcos Luis da Silva, sob o crivo do contraditório, disse que: a) eu sou usuário e fui buscar três papéis de cocaína, maconha não; b) eu não lembro da mão de quem eu peguei; c) eu adquiri a droga de uma pessoa que estava de moleton vermelho, por R\$ 20,00; d) como é um ponto de drogas fica bastante usuários de drogas e na hora do corre, corre todo mundo correu; e) havia outras pessoas que correram que a polícia não pegou; f) eu fui levado junto com outras pessoas para a Delegacia; g) não acompanhei a revista pelos militares; h) eu fui revistado e no meu bolso somente foram encontrados três papéis, mas a revista dos dois eu não vi; i) não vi ninguém arremessar uma sacola no telhado (fls. 9 e 227/229). Em juízo a testemunha Marcelo Scorzelli disse que: a) nós estávamos em operação na região de Mauá; b) houve uma denúncia de que na travessa havia indivíduos praticando o tráfico de drogas, inclusive com as características deles; c) fomos até o local e três pessoas correram na nossa direção, um era o Marcos que estava comprando os entorpecentes, o João e o Mateus arremessaram sacolas no telhado, em que havia maconha e cocaína; d) Mateus levava uma sacola e o Mateus levava outra sacola e eles lançaram as sacolas em um telhado, bem na nossa frente; e) o Marcos confirmou que estaria ali comprando e correu, porque se assustou; f) o Marcos disse que entregou R\$ 20,00 para o Mateus e receberia as drogas do Vitor, inclusive foi feita uma revista no Mateus e ele tinha essa nota de R\$ 20,00; g) a denúncia dizia que um estava de moleton vermelho, o João Vitor, e um de blusa escura, o Mateus; h) eu visualizei três pessoas; i) eu não vi outras pessoas correrem; j) não conhecia os réus; k) o policial Willian Isaac da Silva sabe a mesma coisa que eu, ele estava comigo e há uns uns 10 metros atrás de mim estava a equipe de reportagem da TV Bandeirantes, que filmou eles jogando as sacolas no telhado (fls. 7/8 e e 227/229). Judicialmente, a testemunha Willian Isaac da Silva disse que: a) era uma operação, as viaturas fecharam todas as vielas e eles ficaram acudados, parados; b) eu visualizei o usuário entregar dinheiro; c) os dois estavam com sacolas nas mãos e foram arremessadas no telhado; d) no telhado haviam duas sacolas; e) nós estávamos em operação ABC mais seguro e o COPON passou as características dos indivíduos que estavam praticando o tráfico de drogas; f) eu consegui ver eles na pratica de venda de entorpecentes e quando eu visualizei eles lançaram as sacolas; g) nas sacolas haviam crack, maconha e cocaína; h) não lembro as quantidades das drogas; i) no bolso do Mateus havia R\$ 40,00; j) Mateus é o que estava com a camisa escura; k) não conhecia os réus, não tenho dúvidas de que foram eles que lançaram as sacolas que estavam com as drogas, no telhado (fls. 10/11 e 227/229). A testemunha Wesley Chande Carvalho de Souza, em juízo, disse que: a) eu conheço o João há muito tempo; b) João trabalha e estava estudando até o comecinho do ano; c) no dia 21 de abril, próximo às 17h:30min, até às 18 horas eu estava com o João; d) eu cheguei do serviço e João também; e) fomos comprar maconha, eu fiquei no aguardo e João Vitor não voltou mais (fls. 227/229). A testemunha Valdecino Gonçalves Ferreira, em juízo, disse que: a) eu conheço o João Vitor, porque ele trabalhou comigo por 40 dias; b) o último dia que ele trabalhou para mim foi no dia 21/04, até o meio dia, era um feriado (fls. 227/229). O réu Mateus Costa Cardoso Landim, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) não conhecia os policiais que me prenderam; c) não sei o motivo de eles estarem

me acusando, fui comprar drogas, sou usuários de crack; d) não conheço o João Vítor; e) eu não tinha sacola nas mãos e quando sai correndo não joguei nada no telhado; f) havia mais pessoa lá; g) a pessoa que estava vendendo drogas correu e não foi preso; h) faço tratamento de drogas, desde 2018 (gravação audiovisual e fls. 13). Por fim, ao ser interrogado judicialmente, o réu João Vitor Viana da Silva disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) não conhecia os policiais; c) não sei o motivo de os policiais terem dito que eu estava com um bolsa nas mãos e ao vê-los ter corrido e jogado a suposta bolsa no telhado; c) eu fui lá comprar uma maconha; d) nunca vi o Mateus na minha vida; e) no dia 21 de abril eu trabalhei até o meio dia (gravação audiovisual e fls. 12). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/4), auto de exibição e apreensão (fls. 20), laudo de constatação provisória (fls. 22/25), laudo de exame de corpo de delito do réu Mateus (fls. 163/164), exame químico toxicológico definitivo (fls. 165/167), como também pelos depoimentos das testemunhas Marcos Luis da Silva (fls. 9 e 227/229), Marcelo Scorzelli (fls. 7/8 e 227/229), Willian Isaac da Silva (fls. 10/11 e 227/229), Wesley Chande Carvalho de Souza (fls. 227/229), e Valdecino Gonçalves Ferreira (fls. 227/229), foi comprovado que as testemunhas Marcelo e Willian são policiais militares e foram acionados, via COPOM, sobre notícia de tráfico de drogas praticado no local dos fatos por dois indivíduos, um de moletom vermelho e outro de camiseta escura. Eles foram para o local dos fatos e viram os dois indivíduos em atividade típica de venda de drogas, então foram aborda-los, eles saíram correndo e cada um deles jogou a sacola que trazia consigo em cima de um telhado, mas foram detidos e as sacolas apreendidas. O réu Mateus estava com as vestes de cor escura e o réu João Vítor com o moletom vermelho. Outrossim, foi detido a testemunha Marcos Luis que eram um usuário de drogas que estava comprando drogas deles e havia entregue R\$ 20,00 ao réu Mateus, que foram apreendidos com este réu. Na sacola que o réu João Vítor trazia consigo foram apreendidos 49 porções de maconha, pesando 43,96g, e 75 porções de cocaína, pesando 46,02g, e na sacola que o réu Mateus trazia consigo foram apreendidos 30 porções de crack, pesando 6,87g. As autodefesas dos réus restaram isoladas nos autos, não sendo o caso da desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, pretendida pela defesa técnica do réu João Vítor, em decorrência da "natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente" (artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006), conforme já fundamentado. As testemunhas Wesley e Valdecino não presenciaram os momentos das prisões dos réus (fls. 227/229). A testemunha Marcos confirmou que comprou drogas e entregou uma nota de R\$ 20,00 a um dos traficantes, justamente a que foi encontrada com o réu Mateus (fls. 9 e 227/229). Os documentos de fls. 119/129, por si só, não comprovam que o réu Mateus estava sob o efeito de drogas, ao tempo da ação, muito menos que ele não tinha capacidade de entendimento e de autodeterminação, nem que estava com esta capacidade reduzida. Por fim, desconsidero como provas, tanto as imagens juntadas pelo cartório (fls. 253), como também as juntadas pela defesa do réu Mateus (fls. 254/255), porque não se sabe a origem delas, já que foram juntadas da internet e não foi obedecida a determinação judicial para a juntada das imagens pela TV Bandeirantes (fls. 227/228, 238, 241, 251 e 256). Friso que a juntada das imagens foi determinação judicial (fls. 227/228) e por se tratarem de réus presos, a TV Bandeirantes não ter fornecido as imagens e as partes expressamente terem dispensado esta prova (gravação audiovisual), o juízo passou ao interrogatório dos réus, debates e julgamento. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação dos réus Mateus Costa Cardoso Landim e João Vitor Viana da Silva, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. a) Em relação ao réu Mateus: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (49 porções de maconha, pesando 43,96g, e 75 porções de cocaína, pesando 46,02g – pertencentes ao réus João Vitor - e 30 porções de crack, pesando 6,87g, pertencente ao réu Mateus – fls. 20, 22/25 e 165/167) não permitem aumentar a pena, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 44 e 47/48). Na segunda

fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento a serem apreciadas, contudo reduzo a pena em 2/3, passando para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Ressalto que entendo que poderia me utilizar da natureza e da quantidade das drogas, para fins de obstar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Contudo o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 712, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.887.511/SP, passaram a entender que não é possível a utilização da natureza e da quantidade das drogas na terceira fase de aplicação da pena. Outrossim, não há outro critério para a redução da pena entre 1/6 e 2/3, a não ser a natureza e a quantidade das drogas, mas, como já dito, ela não pode ser utilizada na terceira fase da dosimetria da pena, por esta razão reduzi a pena no máximo de 2/3, pois, não havendo outro critério a ser utilizado, e não há, o juiz não poderia quantificar a pena a seu bel-prazer, pois agindo assim estaria violando o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Inclusive, nos processos nos 1500527-09.2020.8.26.054 (fls. 318/325) e 1501072-79.2020.8.26.0540 (fls. 426/435), que tramitam nesta Vara, foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça que este magistrado recalculasse a pena com base nestes parâmetros. Desta maneira, por segurança das relações jurídicas, passo a dosar a pena, conforme a mencionada orientação dos Tribunais Superiores. No caso do tráfico de drogas, o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 determina que o juiz “na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” – (grifei). Ou seja, a fixação da pena compreende a dosimetria e o regime inicial de cumprimento, tanto que o legislador ressaltou que a natureza e a quantidade das drogas e a conduta social preponderam sobre o artigo 59 do Código de Processo Penal, e este artigo (59 do Código de Processo Penal) deve ser considerado na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, conforme prevê o artigo 33, § 3º, do Código de Processo Penal. Desta maneira, fixo o regime inicial de cumprimento da pena semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, a despeito de a pena ser inferior a quatro anos e o réu não ser reincidente (fls. 44 e 47/48), a natureza e quantidade das drogas apreendidas (49 porções de maconha, pesando 43,96g, e 75 porções de cocaína, pesando 46,02g – pertencentes ao réus João Vitor - e 30 porções de crack, pesando 6,87g, pertencente ao réu Mateus – fls. 20, 22/25 e 165/167), preponderam sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, e o artigo 59 do Código Penal deve ser levado em consideração na dosimetria da pena, segundo preceitua o artigo 33, § 3º, do Código Penal. Neste sentido a jurisprudência: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E RECUSA DE ENVIO À PGJ. RECUSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO PARQUET. ANUÊNCIA DO MAGISTRADO. PROPOSTA DE REVISÃO REQUERIDA A DESTEMPO PELA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FÉLIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe de 3/4/2018. 2. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à

propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos. Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 4. Conforme o acórdão ora impugnado, o requerimento de revisão do não oferecimento de proposta do ANPP, para fins de análise do órgão superior do Ministério Público local, ocorreu a destempo pela defesa, deixando que a instrução criminal fluísse regularmente. 5. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. No caso, embora estabelecida a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão, a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos (16 porções de maconha, pesando 66,2 gramas; 44 porções de cocaína, pesando 39,6g; 33 porções de crack, pesando 7,1g; - 13/16 e 70/71) , utilizadas na escolha do patamar de diminuição do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, o semiaberto, em razão da quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos. 7. Habeas corpus não conhecido.” - (grifei). (HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020). “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSIÇÃO JUSTIFICADA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte a quo afastou a aplicou a minorante considerando as circunstâncias fáticas da causa, qual seja, a quantidade e variedade das drogas apreendidas. Entender de forma diversa exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. A quantidade e natureza das drogas apreendidas - 116 porções de maconha- constituem fundamentos idôneos para o agravamento do aspecto qualitativo da pena, ou seja, para a fixação de regime mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Tendo a reprimenda ultrapassado os 4 anos de prisão, a circunstância judicial desfavorável (quantidade da droga) justifica a fixação do regime inicial semiaberto, segundo a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.” - (grifei). (AgRg no AREsp 1671723/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não

conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. III - Ademais, a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta requer fundamentação específica, baseada em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. IV - No caso, aplicada a pena de 2 anos de reclusão, entendo que deve ser estabelecido o regime inicial intermediário, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, e do art. 42 da Lei de Drogas. A quantidade e variedade dos entorpecentes podem ser utilizadas como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06. V - O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o HC n. 97.256/RS, reconhecendo a inconstitucionalidade da parte final do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, passou a admitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. VI - Na hipótese em análise, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (16 porções de maconha, pesando 66,2 gramas; 44 porções de cocaína, pesando 39,6g; 33 porções de crack, pesando 7,1g; - 13/16 e 70/71) não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consoante o disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa da benesse em tela. Habeas corpus não conhecido. Ordem de ofício apenas para fixar o regime semiaberto para resgate da reprimenda, mantido os demais termos da condenação." - (grifei). (HC 581.356/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020). "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO ADEQUADO. AFASTAR CARÁTER HEDIONDO. PLEITO PREJUDICADO. DETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Concluído pelas instâncias antecedentes, com fulcro nos elementos constantes dos autos e no fato de registrar atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, que o agravante se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. 4. Embora o agente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento das sanções impostas, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade e natureza de entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 5. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão, é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 6. Fica prejudicado o pleito de afastamento do caráter hediondo do delito, pelo não reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado. 7. Noticiado o trânsito em julgado da ação penal, caberá ao Juízo de execução penal averiguar a possibilidade de estabelecimento de regime mais brando diante do desconto do período em que o agravante permaneceu preso preventivamente. 8. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 573.149/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020) - (grifei). Não substituo a pena do réu, porque, nos

termos do artigo 44, § 3º, do Código Penal, não é socialmente recomendável, pela natureza e quantidade das drogas (49 porções de maconha, pesando 43,96g, e 75 porções de cocaína, pesando 46,02g

- pertencentes ao réus João Vitor - e 30 porções de crack, pesando 6,87g, pertencente ao réu Mateus - fls. 20, 22/25 e 165/167), fato concreto que impede a substituição.b) Em relação ao réu João Vitor: Pelos mesmos motivos da fundamentação da pena do réu Mateus (item a), fixo a sua pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, no regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena (fls. 49 e 52/53). Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (réu João Vitor - fls. 28 - e réu Matheus - fls. 31). Determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 20), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 20, 22/25 e 165/167). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO os réus JOÃO VITOR VIANA DA SILVA (R.G. nº 55.873.188 - filho de Jeferson Magno da Silva e Elinéia da Silva Viana - fls. 12 e 30) e MATEUS COSTA CARDOSO LANDIM (R.G. nº 55.737.682 - filho de Roberto Daniel Cardoso Landim e Fabiana Silva da Costa - fls. 13 e 27), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Nego aos réus o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, os réus aguardaram todo o trâmite processual presos (fls. 58/59). Oficie-se imediatamente ao estabelecimento penal, no qual os réus estão presos provisoriamente para transferi-los ao regime adequado, nos termos do Súmula vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. Os réus arcarão com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; b) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; c) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; d) lance-se os nomes dos réus no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.